

1521982-93.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: Rafaela Caldeira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional XV - Butantã

Vara: Vara Reg.Oeste de Viol. Dom. e Fam.Cont.Mulher

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE ISENÇÃO DE PENA ATINENTE À EMBRIAGUEZ, PRECONIZADA NO ART. 28 DO CÓDIGO PENAL, OU PELA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 2.º DO CITADO DISPOSITIVO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ACTIO LIBERA IN CAUSA. PRECEDENTES. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional XV - Butantã

Vara Reg.Oeste de Viol. Dom. e Fam.Cont.Mulher

Avenida Corifeu de Azevedo Marques,148/150, Compl. do Endereço da Vara <<

Informação indisponível >> - Butanta

CEP: 05582-000 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 4503-9506 - E-mail: frbutantavioldom@tjsp.jus.br

1521982-93.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1521982-93.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MANOEL SEVERINO DA SILVA

Prioridade Idoso

C O N C L U S ã O

Em, 27/04/2022 10:22:30, faço conclusos estes autos à MM Juíza de Direito, Dra. Rafaela Caldeira Gonçalves. Eu, Rafaela Caldeira Gonçalves, Juiz de Direito, subscrevi.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafaela Caldeira Gonçalves

VISTOS.

MANOEL SEVERINO DA SILVA devidamente qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 24-A, da Lei. 11.340/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h", e artigo 147, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alíneas "f" e "h", na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Isto porque, consoante a denúncia (fls. 86/89), no dia 18 de outubro de 2020, por volta das 15h36min, na Avenida Valdemar Roberto, n.º 627, Rio Pequeno, nesta cidade e comarca, teria descumprido decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, mais especificamente as de proibição de aproximação e contato, em favor de sua irmã, Severina Maria da Silva, que conta com mais de 60 (sessenta) anos de idade. Teria, ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, prevalecendo-se

das relações domésticas e familiares, na forma da Lei nº 11.340/2006, ameaçado Severina de causar-lhe mal injusto e grave.

Na oportunidade, o acusado foi preso em flagrante (fls. 01/02), tendo havido a conversão do flagrante em prisão preventiva (fls. 63/66). No curso do processo, a prisão cautelar restou revogada (fls. 144/150).

A denúncia foi recebida (fls. 98/100) e o acusado citado pessoalmente (fls. 117), tendo-lhe sido nomeado defensor dativo (fl. 120), quem apresentou resposta à acusação em seu favor (fls. 127/128), após o que foi proferida decisão nos termos do artigo 397 do Código de Processo Penal, determinando que o feito atingisse a fase instrutória (fls. 144/150).

Durante a instrução criminal (fls. 239/240), foram ouvidas a vítima (fl. 241) e 01 (uma) testemunha de acusação (fl. 242), de sorte que ao final foi decretada a revelia do acusado.

Em sede de memoriais (fls. 244), o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, com a consequente condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Com relação a ambos os delitos, pleiteou que, na primeira fase da dosimetria da pena, fossem as penas-bases severamente majoradas, considerando o histórico de violência demonstrado pelo réu e sua personalidade desvirtuada, conforme verifica-se da oitiva da testemunha. Ademais, salientou que o réu seria portador de maus-antecedentes (fls. 102/107), em razão de condenação anterior transitada em julgada, em qual já decorreu o período depurador da reincidência. Na segunda fase da dosimetria da pena, com relação a ambos os delitos, pleiteou a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal. No mais, no tocante ao delito de ameaça, requereu o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f". Por fim, pugnou pelo reconhecimento do concurso material de crimes e ainda a fixação do regime semiaberto de cumprimento de pena.

A Defesa, também em sede de memoriais (fls. 245/249), requereu a improcedência da pretensão punitiva acusatória, com a consequente absolvição do acusado, nos moldes do artigo 386, inciso V ou VII, ambos do Código Penal, sustentando, para tanto, a insuficiência de provas aptas a sustentar um édito condenatório. Argumentou que, em razão de estar embriagado, o réu sequer possuía o animus de concretizar as ameaças. No mais, asseverou não haver provas fáticas suficientes a comprovar que o acusado possuía ciência das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, tendo em vista que a vítima, em sua oitiva, relata ter se valido de terceiro para informá-lo. Subsidiariamente, requereu, na primeira fase da dosimetria da pena, a fixação da pena-base em seu mínimo legal. Ainda, solicitou a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais favorável ao acusado.

Finalmente, verifica-se que, a fls. 144/150 dos autos, foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima e em desfavor do réu, quais sejam: (i) proibição de contato por qualquer meio de comunicação (e-mail, mensagem de texto, telefone, carta e, inclusive, interposta pessoa), (ii) bem como frequência dos locais onde esteja a ofendida (residência, local de estudo, trabalho e ou lazer), tudo nos termos do artigo 22, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei nº 11.340/06.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva acusatória é integralmente procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1/2), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 07/11), pela cópia da decisão concessiva de medidas protetivas a fls. 21/23 dos autos e pelos termos de audiência de custódia de fls. 91/93, nas quais deferidas medidas protetivas também em favor da ofendida e, ainda, pelos demais elementos colhidos durante ambas as fases da persecução penal, inquisitiva e judicial.

No que toca à autoria delitiva, a vítima Severina Maria da Silva declarou que o réu é seu irmão, sendo que este, quando está sob efeito de bebida alcoólica, demonstra comportamento muito violento. Informou que o réu residiu em sua casa durante 09 (nove) anos, período no qual ela e seus familiares buscavam oferecer suporte ao acusado, sem, contudo, obter resultados positivos dos esforços empreendidos. Narrou que, há pelo menos três anos, já não mais morava com o réu. Detalhou que o acusado

passou a residir em sua casa uma vez que “ele tava muito largado, muito dependente e, depois, começou a ficar muito agressivo” (sic). Todavia, a convivência tornou-se insustentável, vez que ficava em sua residência acompanhada apenas por seus três netos e o comportamento agressivo e ameaçador do acusado lhe provocava temor. Questionada, disse que, à época dos fatos, o réu passou a ameaçá-la, chegando a dizer que “que no dia que ele me pegasse, ele me mataria” (sic), dirigindo semelhantes ameaças ao seu filho. Informou que, após os fatos apurados neste processo, não teve mais qualquer contato com o réu. Indagada, relatou que o acusado tinha ciência sobre as medidas protetivas deferidas em seu desfavor, pois a ofendida havia informado para um de seus irmãos, que contou ao réu. Afirmou que o réu chegou a ameaçá-la inclusive diante de testemunha. Perguntada, informou acreditar que, na data do ocorrido, o acusado encontrava-se sob efeito de bebida alcoólica, “porque ele fica muito agressivo, ele fica falando palavras muito pesadas, ele fica cambaleando” (sic). Aduziu que o réu foi preso em flagrante, enquanto ele a ameaçava. Contou que já possuía outras medidas protetivas deferidas em desfavor do acusado, mas que ele não as respeitava. Manifestou interesse em manter as medidas protetivas, pois acredita terem reduzido a procura pelo réu. Disse que “Em 2017 (dois mil e dezessete), 2018 (dois mil e dezoito), eu fiz medida protetiva. Acho que eu tenho 04 (quatro) medidas protetivas, porque são 09 (nove) anos tentando fazer com que ele enxergasse, ele melhorasse, e não teve a solução” (sic), confirmando, ato contínuo, sofrer ameaças pelo réu há, pelo menos, 09 anos, sobretudo quando ele bebia, aduzindo que “quanto ele não bebia, tudo bem, mas quando ele bebia, aí ele fazia isso”, “se ele bebesse muito, ele se transformava” (sic). Questionada sobre o paradeiro do réu, contou que, após a liberdade provisória ter sido concedida ao acusado, não mais teve qualquer tipo de contato com ele. Relatou não saber se o acusado teria se mudado para outro estado, mas que acredita que não, vez que conhecidos seus já viram o acusado pelas ruas de São Paulo, embora nunca perto da residência dela. Informou que, no endereço dos fatos, residem ela, seu filho e sua cunhada, sendo um terreno grande com 03 (três) casas. Negou que este fosse o endereço do acusado, pois, à época dos fatos, ele morava “de favor” (sic) na casa da ofendida. Declarou que o acusado se dirigiu a casa do irmão da vítima por cerca de 02 (duas) vezes, ocasiões em que as tentativas de diálogo com o acusado restaram frustradas. Questionada sobre a frequência na qual as ameaças ocorriam, proferiu que “às vezes, uma vez por semana, às vezes 02 vezes por semana” (sic). Aduziu que, à data dos fatos, contava com 62 (sessenta e dois) anos de idade. Narrou que o acusado já ameaçou sua ex-esposa, tendo ela registrado a ocorrência. Ressaltou que, após os fatos, não passou por atendimento psicológico, mas que tal fato causou impactos negativos em sua vida, pois “alterou, porque eu não tinha problema de pressão alta e fiquei muito. Pra você ter noção, uma vez ele bebeu tanto, que meu filho, que trabalhava longe, esse homem não deixou ninguém dormir, ela arrancou o relógio da luz pra gente ficar no escuro” (sic). Acentuou não saber se o acusado faz consumo de entorpecentes, somente sabendo sobre a bebida alcoólica. Negou que o acusado já tivesse sido internado em razão do consumo abusivo de drogas. Questionada, contou receber benefícios do LOAS, motivo pelo qual não possui interesse pelo projeto Tem Saída. Por fim, manifestou interesse em ser intimada pelo Whatsapp, mas narrou possuir dificuldades para utilizar o aplicativo. A testemunha de acusação, Rogério Oliveira Gonçalves, informou ter sido acionado para atender ao chamado e, ao chegar no local, constatou que acusado estava bastante alterado, de modo que parecia ter ingerido bebida alcoólica ou “algo parecido” (sic). Aduziu ter sido informado, na cena dos fatos, sobre a existência de medida protetiva em favor da vítima. Acrescentou que o acusado parecia estar alterado por conta de dinheiro que a vítima supostamente lhe devia, ou por conta da casa. Declarou que ele realmente teria ameaçado a ofendida. Questionado, contou que a vítima declarou que o acusado a havia ameaçado, contudo a testemunha não soube dizer quais teriam sido as ameaças mencionadas. Negou ter atendido outra ocorrência envolvendo as partes. Negou ter perguntado ao réu se ele possuía conhecimento sobre as medidas protetivas deferidas em seu desfavor, uma vez que este se encontrava alterado. Por fim, negou ter presenciado alguma ameaça, somente tendo se valido do relato da vítima e do fato de o acusado estar muito alterado.

Repise-se que, diante da ausência do réu, sua revelia foi decretada por este Juízo (fls. 239/240).

Tecidas as considerações sobre os elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, passa-se à análise da procedência das imputações formuladas em face do acusado, não sem antes, contudo, mencionarem-se dois aspectos probatórios comuns a todos os delitos praticados.

Com efeito, em que pese a notícia de que o acusado estaria embriagado, nenhum elemento colhido dá conta de que ele apresentaria efetiva dependência patológica de tais substâncias. Outrossim, frise-se que irrelevante eventual estado pontual de embriaguez de MANOEL no momento da prática dos fatos, dado que a influência de substância alcoólica seria, no caso, inapta a eximi-lo de responsabilização penal, por força do disposto no artigo 28, inciso II, do Código Penal, considerando tratar-se de embriaguez voluntária, incapaz de excluir sua culpabilidade. A este respeito, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE ISENÇÃO DE PENA ATINENTE À EMBRIAGUEZ, PRECONIZADA NO ART. 28 DO CÓDIGO PENAL, OU PELA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 2.º DO CITADO DISPOSITIVO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ACTIO LIBERA IN CAUSA. PRECEDENTES. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que "nos termos do art. 28, II, do Código Penal, é cediço que a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito." (AgInt no Resp 1.548.520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016; sem grifos no original). [...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1551160/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 28/05/2020) (grifou-se)

Em segundo lugar, importante pontuar o entendimento consolidado dos tribunais pátrios acerca do especial valor probatório conferido às declarações da ofendida na apuração de crimes havidos no contexto doméstico-familiar contra a mulher, em especial quando pautadas pela coerência e segurança, como no caso dos autos. Nesse sentido:

"APELAÇÃO - Ameaça no âmbito da violência doméstica (artigo 147, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal) - Sentença condenatória - Apelo da defesa requerendo a absolvição por atipicidade de conduta - Declarações da vítima prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção - Inexistência de circunstâncias que lhes retirem a idoneidade - Palavra da vítima que tem relevância no contexto probatório, o qual é suficiente a ensejar a condenação - Condenação mantida - Dosimetria e regime bem aplicados e fundamentados - RECURSO NÃO PROVIDO". (TJSP; Apelação Criminal 1500388-02.2019.8.26.0311; Rel. (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 20/03/2021; Data de Registro: 20/03/2021) (grifou-se) Outro não é o entendimento reiterado do C. Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE SERIEDADE DA AMEAÇA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR DE IDADE. MOTIVAÇÃO. CIÚME EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. [...] 4. Ordem denegada. (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018) (grifou-se).

Feita esta importante ressalva, é de se considerar que o arcabouço probatório

trazido aos autos ao longo da instrução criminal torna imperioso o desfecho condenatório, vez que, ao longo do processo, os fatos narrados na peça acusatória restaram comprovados com a necessária certeza, nos termos do exposto a seguir.

a)Do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência

Em primeiro lugar, de rigor mencionar que, anteriormente aos fatos apurados neste processo, foram deferidas as seguintes medidas protetivas em desfavor do acusado:

(i) nos autos da Ação Penal nº 1500167-67.2020.8.26.0704: (i) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, limite mínimo de trezentos metros de distância entre estes e o agressor; (ii) proibição de contato por qualquer meio de comunicação (e-mail, mensagem de texto, telefone, carta e, inclusive, interposta pessoa), bem como (iii) frequência dos locais onde esteja a ofendida (residência, local de estudo, trabalho e ou lazer), conforme decisão prolatada em 04/02/2020 (fls. 39/41 daqueles autos);

(ii) nos autos da Ação Penal nº 1504075-08.2020.8.26.0228: (a) proibição de se aproximar (a menos de 300 metros) da vítima; (b) proibição de manter qualquer tipo de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação e mesmo por intermédio de terceiros; (c) proibição de frequentar os mesmos lugares que a ofendida, mesmo que tenha chegado anteriormente ao local, conforme decisão exarada no bojo de audiência de audiência de custódia realizada em 21/02/2020 (fls. 55/58 daqueles autos).

Frise-se que, ao contrário do que sustenta a defesa técnica, o réu restou sobejamente intimado do deferimento da medida deferida nos autos do processo nº 1504075-08.2020, uma vez que estava presente na audiência de custódia quando do deferimento das mesmas, tendo sido, inclusive, cientificado acerca das consequências do seu descumprimento. Destaque-se, ainda, que os termos da referida audiência de custódia foram juntados aos presentes autos pelo Ministério Público quando do oferecimento da denúncia (fls. 90/93).

Inconteste, portanto, o descumprimento da referida medida, vez que o réu foi preso em flagrante no portão da residência da ofendida, conforme se extrai dos depoimentos prestados pelos policiais condutores em sede inquisitorial (fls. 03/04), bem como dos depoimentos colhidos em audiência.

Assim, diante do robusto arcabouço probatório no sentido de que o réu dolosa e deliberadamente descumpriu as medidas protetivas determinadas em seu desfavor e do afastamento das teses defensivas, de rigor a condenação do acusado.

b)Do crime de ameaça

As provas produzidas são igualmente aptas a ensejar o desfecho condenatório no tocante ao crime de ameaça praticado contra a vítima Severina, visto ratificarem, à míngua de dúvidas, que o acusado fez promessa de mal injusto e grave contra esta ofendida, dizendo-lhe que a mataria. Com efeito, a narrativa fornecida por esta vítima em Juízo, para além de minuciosa e sólida, guarda consonância não apenas com suas declarações em solo policial (fls. 05/06), mas também com o relato dos policiais militares (fls. 03/04).

Pontue-se ser impossível o acolhimento da tese defensiva de que, em razão da embriaguez do réu, bem como diante do contexto de discussão, não haveria, na fala do réu, qualquer intuito de concretizar as ameaças proferidas, sendo sua conduta atípica. E isso porque a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado não se afigura como elemento normativo do tipo do artigo 147 do Código Penal, sendo, portanto, despicienda. Afinal, como entendem os tribunais superiores, o bem jurídico tutelado pela supracitada norma incriminadora é a tranquilidade psíquica da vítima, consumando-se o delito no momento em que o infrator expõe à vítima a sua intenção de causação de algum mal. Nesse sentido:

"1. O fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito. Além disso, o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização. (HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018)."

Não há nenhuma dúvida de que as ameaças sofridas pela vítima lhe causaram impacto emocional e temor, seja porque tais fatos levaram a registrar a ocorrência contra o acusado, seja ainda porque, consoante por ela mesma narrado, teria ela notado seu estado de saúde se deteriorar em razão das constantes perturbações ao seu psicológico.

No mesmo sentido, incabível a alegação defensiva no sentido de serem as provas amealhadas aos presentes autos insuficientes para a condenação. Isso porque, como já se pontuou, em crimes transcorridos no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima conta com especial destaque, sendo certo que, em juízo, a vítima Severina apresentou uma narrativa coerente, coesa e consistente com o seu depoimento prestado em sede policial.

Ademais, também foi ouvido em juízo o Sr. Roberto, policial militar responsável por realizar a prisão em flagrante do réu. E nem se diga que, por não ter presenciado as ameaças, seu testemunho não seria válido, afinal, o policial militar esteve no local dos fatos e ouviu o relato da vítima sobre as ameaças sofridas, minutos após o ocorrido, tendo, inclusive, concluído estar diante de uma situação de flagrante delito. A bem da verdade, o testemunho do policial Roberto configura o que a doutrina convencionou chamar de testemunho indireto. E, embora tal meio de prova não encontre regulamentação na legislação nacional, fato é que a jurisprudência dos Tribunais Superiores já cuidou de definir o valor do referido testemunho. Veja-se, por exemplo, ilação do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) 3. A prova testemunhal, mesmo que indireta (ouviu da vítima o relato), produzida em juízo, mediante o contraditório e ampla defesa, que, de maneira coerente e harmônica, ratifica o depoimento da vítima em fase inquisitorial, é suficiente para a condenação" (STJ, 5ª T., AgRg no REsp 1.387.883/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 25/10/2017).

Destarte, afastada as teses ventiladas pela defesa, imperiosa a condenação do réu, pelo que integralmente procedente a pretensão acusatória.

Passo, então, a aplicar a pena.

Do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência

À luz do artigo 59 do Código Penal, imperioso destacar a gravidade da conduta social e da personalidade do réu, sobretudo considerado o histórico de agressões de natureza psicológica empreendidas pelo réu em desfavor da vítima. Em audiência, a vítima narrou que, durante anos e anos, foi vítima das ameaças do réu que, por vezes, ocorriam mais de uma vez na mesma semana. Os relatos oferecidos pela vítima Severina demonstram que o réu possui personalidade distorcida, causando sensação de intranquilidade constante à vítima, valendo-se de armas brancas para ameaçar e, ainda, procedendo à destruição de patrimônio, o que impõe a valoração negativa das citadas circunstâncias judiciais.

Igualmente negativos os antecedentes criminais do réu, vez que possui condenação criminal, cuja pena foi cumprida e extinta há mais de 05 anos, conforme se extrai da folha de antecedentes aposta a fls. 102/107.

Assim, majoro a pena base para fixá-la em 6 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, forçoso o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, "h" do Código Penal, uma vez que, à data dos fatos, a vítima contava com 62 anos de idade. Ademais, também de rigor o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, "e" da referida lei, uma vez que o crime foi cometido em detrimento da irmã do acusado. Sendo assim, majoro a pena em 1/6, para cada agravante, fixando-a em 8 (oito) meses de detenção, pena esta que torno definitiva, à míngua de causas especiais de aumento ou diminuição da pena. Anote-se que, a despeito de não ter o órgão ministerial incluído a agravante referente ao parentesco entre a vítima e o réu na tipificação legal constante da denúncia, tal fato não obsta o seu reconhecimento, visto que referida relação de parentesco foi expressamente mencionada na exordial acusatória em relação a tais delitos. Destarte, considerando-se que o réu se defende dos fatos constantes da denúncia e não da capitulação legal a eles atribuída pelo órgão ministerial, possível a incidência da circunstância agravante.

À luz do disposto no artigo 33, caput e parágrafo 2º, c, do Código Penal, em

especial diante da reprimenda imposta e por ser o réu tecnicamente primário, deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena em REGIME ABERTO.

Diante das circunstâncias judiciais sopesadas em desfavor do acusado, não há que se falar em aplicação do artigo 44 do Código Penal, notadamente em virtude do comando contido em seu inciso III, por ser evidente a insuficiência da substituição para a adequada reprovação e prevenção do crime. E mais: o descumprimento de medida protetiva, por si só, já configura violência psicológica, nos termos do artigo 7º, inciso II da Lei Maria da Penha, a desincentivar a substituição também conforme o artigo 44, inciso I do Código Penal.

Deixa-se, ainda, de suspender a execução da pena, dadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e porque seria mais gravoso ao acusado que o cumprimento da pena em regime aberto. Isto porque, diante da peculiaridade do caso, em face da quantidade de pena privativa de liberdade imposta (08 meses), afigura-se desproporcional a aplicação daquele instituto, em qualquer de suas formas (simples ou especial), vale dizer, o acusado ficaria vinculado ao processo por 02 anos quando a sua reprimenda, repita-se, foi de 08 (sete) meses de detenção, em regime aberto. Na prática, o sursis revela-se mais gravoso que a própria execução da reprimenda privativa de liberdade, o que não pode subsistir, sob pena de desvirtuamento deste instituto, concebido para funcionar como alternativa aos rigores do encarceramento em um dos regimes prisionais existentes no Código Penal.

Do crime de ameaça

Novamente à luz do disposto no artigo 59 do Código Penal, mais uma vez se faz necessário destacar a conduta social e a personalidade ameaçada do acusado, em especial dentro do contexto doméstico-familiar, dadas as narrativas de recorrentes episódios de violência psicológica. Também se valora negativamente os antecedentes do acusado, pelas razões supra expostas. Assim, majora-se a pena-base para fixá-la em 4 (quatro) meses de detenção.

No que tange à segunda-fase da dosimetria, imperioso o reconhecimento das agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “h”, pelas razões previamente expostas. Ademais, presente a agravante prevista no artigo 61, inciso II, “f”, uma vez que o crime se deu no contexto doméstico, com a presença de violência psicológica contra a mulher.

Assim, majoro a pena em 1/6 para cada agravante reconhecida, fixando-a em 6 (seis) meses de detenção, que torno definitiva à míngua de causas especiais de aumento ou diminuição de pena.

À luz do disposto no artigo 33, caput e parágrafo 2º, c, do Código Penal, em especial diante da reprimenda imposta e por ser o réu tecnicamente primário, deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena em REGIME ABERTO.

Diante das circunstâncias judiciais sopesadas em desfavor do acusado, não há que se falar em aplicação do artigo 44 do Código Penal, notadamente em virtude do comando contido em seu inciso III, por ser evidente a insuficiência da substituição para a adequada reprovação e prevenção do crime. E mais: o crime de ameaça, por si só, já configura violência psicológica, nos termos do artigo 7º, inciso II da Lei Maria da Penha, a desincentivar a substituição também conforme o artigo 44, inciso I do Código Penal.

Deixa-se, ainda, de suspender a execução da pena, dadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e porque seria mais gravoso ao acusado que o cumprimento da pena em regime aberto. Isto porque, diante da peculiaridade do caso, em face da quantidade de pena privativa de liberdade imposta (06 meses), afigura-se desproporcional a aplicação daquele instituto, em qualquer de suas formas (simples ou especial), vale dizer, o acusado ficaria vinculado ao processo por 02 anos quando a sua reprimenda, repita-se, foi de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto. Na prática, o sursis revela-se mais gravoso que a própria execução da reprimenda privativa de liberdade, o que não pode subsistir, sob pena de desvirtuamento deste instituto, concebido para funcionar como alternativa aos rigores do encarceramento em um dos regimes prisionais existentes no Código Penal.

Do concurso de crimes

De rigor a aplicação do concurso material entre o crime de ameaça e o crime de

descumprimento de medidas protetivas de urgência, tendo-se em vista que diversas as condutas, autônomos os desígnios e distintos os bens jurídicos protegidos, atraindo a aplicação do artigo 69 do diploma legislativo aludido. Assim, somam-se as penas referidas, totalizando-se 01 (um) ano e 02 (meses) dias de detenção, a ser concretizada na espécie, fixando-se, pelo já exposto, o REGIME ABERTO como inicial para o cumprimento da reprimenda.

DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO

No que toca ao pedido de reparação mínima de danos, este deve ser acolhido, especificamente para a condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais em favor da ofendida.

Nota-se que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, de cunho imperativo, veio para prestigiar a vítima e conceder-lhe maior celeridade na obtenção da antecipação da indenização, pois, nos termos do artigo 91, inciso I, do Código Penal, trata-se de efeito automático da sentença condenatória definitiva.

Ainda, o dispositivo processual penal mencionado não faz qualquer distinção quanto ao tipo de dano a ser indenizado, se material ou moral.

A respeito do referido artigo evocado, mencionem-se as seguintes considerações de Eugênio Pacelli:

De todo modo, qualquer que seja a leitura que se faça do art. 387, IV, CPP, uma coisa é certa: seja como pena pecuniária, seja como efeito penal da sentença condenatória, seja finalmente, como condenação civil no processo criminal, a demonstração dos valores mínimos deve ser de modo cabal no processo penal, de tal modo que não se corra o risco de se aplicar condenação em valores superiores àqueles a serem futuramente obtidos no juízo cível. Há, portanto, que se estabelecer sobre ele (valor) o contraditório e, torno de sua comprovação (prejuízo efetivamente causado) e razoabilidade da despesa empreendida. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 2ª ed., pág. 821).

A propósito do tema, já se posicionou a doutrina, ao analisar a nova redação do artigo 387 do Código de Processo Penal, dada pela Lei 11.719/08:

"Menciona-se que o magistrado pode fixar um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, levando em conta os prejuízos sofridos pela vítima. Ora, para o estabelecimento de um valor mínimo o juiz deverá proporcionar todos os meios de prova admissíveis, em benefício dos envolvidos, mormente do réu. Não pode este arcar com qualquer montante se não tiver tido a oportunidade de se defender, produzir prova e demonstrar o que, realmente, seria, em tese, devido. (...)

Procedimento para a fixação da indenização civil: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-lo. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa." (in "Código de Processo Penal Comentado", de Guilherme de Souza Nucci, 8ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 691)

No caso dos autos, foram apurados fatos cometidos no contexto violência doméstica e familiar contra a mulher, pelo que se está diante de dano moral "in re ipsa", que dispensa prova para sua configuração. Isto porque não se mostra razoável a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminoso empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Em concordância com as citações colacionadas acima, o que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, é a própria

imputação criminosa – sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o ônus probandi é integralmente do órgão de acusação –, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

"nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (Tema 983, Resp 1675874/MS e Resp 1643051/MS, Relator Ministro Rogério Schiett Cruz, 3ª Seção, unânime, data de julgamento: 28/02/2018).

Desta forma, no caso de violência doméstica, a ofendida está dispensada de apresentar prova de que sofreu dano moral por ter sido vítima de calúnia, difamação, ameaça, lesão e outros delitos, visto que o próprio fato já configura o dano.

Tal entendimento, facilitador da reparação de danos à vítima, está em consonância com a normativa internacional sobre violência de gênero. A Recomendação n. 35 sobre a Violência de Gênero contra as mulheres do Comitê CEDAW, traduzida pelo Conselho Nacional de Justiça, dita o seguinte, no que se refere a reparações:

Fornecimento de reparação efetiva às vítimas/às sobreviventes de violência de gênero. A reparação deve incluir diferentes medidas, tais como a compensação monetária e a prestação de serviços jurídicos, sociais e de saúde, incluindo saúde sexual, reprodutiva e mental, para recuperação completa, satisfação e garantias de não repetição, de acordo com a Recomendação Geral n. 28, a n. 30 e a n. 33. Tais reparações devem ser adequadas, prontamente atribuídas, holísticas e proporcionais à gravidade dos danos sofridos. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Recomendação Geral n. 35 sobre Violência de Gênero contra as Mulheres do Comitê para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW). Série Tratados Internacionais de Direitos Humanos. Tradução: Neri Accioly. Brasília, 2019, p. 32) É, portanto, possível e recomendável a fixação de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso, formulado pela vítima ou pelo Ministério Público, independentemente de instrução probatória específica sobre a extensão do dano.

Na espécie, foi deduzido pedido formal na denúncia (fls. 86/89) em favor das vítima, sendo atendidas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa durante a instrução criminal.

De fato, contém os autos os elementos necessários à fixação da indenização em seu valor mínimo em favor de Severina. No presente caso, além de figurar como sujeito passivo secundário do delito previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, a violência psicológica sofrida pela ofendida, mesmo depois de ter buscado o Poder Judiciário e obtido uma decisão cautelar protetiva, a fim de resguardar sua integridade física e psíquica, certamente abalou o seu estado emocional e psicológico, fato este especialmente perceptível pelo contexto de violência por ela narrado em audiência e também por sua manifestação no sentido de ter percebido uma deterioração de sua saúde em razão do medo experimentado, bem como o seu desejo de ver as medidas protetivas mantidas, a indicar um quadrado de persistente temor, pelo que tal panorama autoriza o arbitramento de valor mínimo para a indenização por dano moral. Anote-se, por outro lado, que o pleito indenizatório por danos materiais não procede, visto que a ofendida não aponta em suas declarações se teria havido prejuízos materiais decorrentes das condutas praticadas pelo réu.

Frise-se ser desnecessário que o Ministério Público indique expressamente a quantia mínima reparatória, já que cabe ao Juízo sentenciante fixar o valor indenizatório inicial, sem prejuízo de a parte vitimada promover, no juízo cível, pedido suplementar, onde deverá evidenciar cabalmente a extensão dos danos suportados.

A respeito da situação econômica do acusado, na fase policial, ele declarou ser ajudante de pedreiro (fls. 33). Em Juízo, foi decretada sua revelia (fls. 271/272), pelo que não puderam ser colhidas informações a tal respeito. Todavia, há indícios, nestes autos, de que o réu é morador de rua, o que, de certo, impacta na sua

condição financeira.

Nesse contexto, à luz do disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal e considerando que se cuida, na esfera criminal, de arbitrar um valor mínimo indenizatório pelo dano sofrido, podendo as vítimas pleitearem, no juízo cível, a indenização integral, fixa-se o valor de meio salário-mínimo em favor da vítima, na soma vigente à época da prática delitativa, acrescido de juros de mora legais e correção monetária desde a citação do réu neste feito. Desde já, anote-se que a execução desta sentença para tal fim far-se-á perante o juízo cível competente. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva acusatória e o faço para CONDENAR o réu MANOEL SEVERINO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso: a) No artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 c.c. artigo 61, inciso II, alíneas "e", "h" do Código Penal; e b) Nos artigos 147, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alíneas "e", "f", e "h" e, todos do Código Penal; na forma do artigo 69 deste último diploma legislativo, à pena de 01 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial ABERTO.

Parcialmente procedente a pretensão indenizatória, tão somente para o pedido de indenização por danos morais, nos moldes supra explicitados.

O acusado foi preso em flagrante em 18 de outubro de 2020 (fls. 01/02) e permaneceu custodiado até 10 de fevereiro de 2021 (fls. 169/175). Nada obstante, tendo-se em vista que foi condenado, nesta oportunidade, a pena a ser cumprida em regime inicial aberto, tem-se que, mesmo diante da aplicação do quanto disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, o regime inicial de cumprimento da reprimenda permanece inalterado, visto já se tratar do mais benéfico ao réu.

Após ter a custódia cautelar revogada, MANOEL deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento da presente ação penal e de manter este Juízo atualizado acerca de seu endereço, pelo que foi decretada sua revelia. Também é certo que responde a outras ações penais envolvendo violência doméstica perante este juízo. Nada obstante, é tecnicamente primário, foi condenado, nesta data, a pena a ser cumprida em regime inicial aberto e de sua folha de antecedentes se extrai a ausência de notícias de que tenha voltado a delinquir desde a prática dos fatos ora apurados. Em audiência, foi noticiado pela ofendida que, depois que ele foi colocado em liberdade, não qualquer contatos ou entevos do acusado com ela, a sugerir que ele esteja cumprindo as medidas protetivas que lhe foram impostas. Assim, ausentes os pressupostos de cautelaridade constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal, concedo-lhe o direito de apelo em liberdade.

Contudo, tendo em vista o histórico de violência no contexto doméstico-familiar entre o acusado e a vítima e a narrativa desta em audiência no sentido de desejar a manutenção das medidas, MANTENHO AS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS A FLS. 144/150, DAS QUAIS O ACUSADO FOI REGULARMENTE INTIMADO A FLS. 173/174, consignando, mais uma vez, que seu descumprimento poderá qualificar a conduta de MANOEL, nos termos do inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei nº 11.340/06, para fins de ter decretada sua prisão preventiva; sem prejuízo de se ver reconhecida também nova prática do crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A da mesma legislação.

Observo, por oportuno, que também permanecem vigentes as medidas protetivas deferidas no âmbito das ações penais nº 1500167-67.2020.8.26.0704 e 1504075-08.2020.8.26.0228, que ensejaram a configuração do crime de descumprimento de medidas protetivas.

Julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, de rigor a condenação do acusado ao pagamento da íntegra das custas e despesas processuais incidentes, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, parágrafo 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003 do Estado de São Paulo.

Todavia, diante dos indícios constantes destes autos de que o réu é morador de rua, sem que se tenha notícia de sua capacidade econômica, defiro ao réu o benefício previsto no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, suspendendo o pagamento das custas.

Finalmente, considerando que o advogado dativo do réu renunciou ao mandato (fls. 228/229), bem como a afirmação do réu no sentido de ser assistido pela Defensoria Pública (fls. 117) oficie-se a d. Defensoria Pública para que, nos termos do

Convênio firmado com a OAB-SP, providencie a nomeação de novo defensor dativo para atuar no presente feito.

Com a vinda do ofício da nomeação, expeça desde já mandado de intimação em nome do d. Defensor dativo para que apresente, nos termos do disposto no artigo 403, § 3º do Código de Processo Penal, defesa escrita em favor do acusado, no prazo de 05 dias.

Acompanhará o mandado de intimação, nos moldes dos Provimentos CSM n. 1492/08, Termo de Compromisso próprio (modelo a seguir) para que, caso assim deseje, observado o disposto no artigo 2º do aludido provimento, anua com sua intimação pelo Diário Oficial Eletrônico dos atos processuais a serem praticados doravante. Em caso positivo, deverá o referido termo ser assinado e entregue ao sr. Oficial de Justiça, no ato imediatamente seguinte após o cumprimento do mandado de intimação, para que que tanto este, quanto aquele, sejam acostados aos autos, como preceitua a mesma norma administrativa supramencionada.

Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu, e a respectiva guia definitiva. Deixo, porém, de determinar a expedição da certidão de honorários em favor do defensor dativo que atuou nesta ação penal em razão de expressa revogação do mandatário neste sentido (fls. 228/229).

P.R.I.C.

São Paulo, 19 de julho de 2022.